

0005573-34.2020.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... rel. Gentil Leite, RT 710/279).

"Tráfico - Apreensão de grande quantidade de maconha - Objetivo de comercialização indiscutível, ainda que se trate de réu dependente da erva entorpecente - Condição de traficante que se prepondera sobre a de viciado, posto que tinha ele o entendimento da ilicitude do tráfico" (TJSP - rel. MARINO FALCÃO, RJTJSP 84/382).

Ademais, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira - SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0005573-34.2020.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005573-34.2020.8.26.0320

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Neide Tossin e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Vistos.

Os réus NEIDE TOSSIN e NELSON ALLE SIMÕES encontram-se denunciados pela suposta prática do delito capitulado pelo art. 33, caput, conforme os fatos narrados na denúncia a qual me reporto.

Regularmente processados, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e os réus foram ao final interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia. A defesa dos réus sustentou inicialmente o cerceamento de defesa, e no mérito, pleiteou a absolvição, fundamentalmente sob o argumento da insuficiência probatória.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO.

Inicialmente, quanto à preliminar sustentada pela douta defesa, respeitado o entendimento, reporto-me ao quanto deliberado às fls. 395/396, não se vislumbrando interesse prático na produção de referida prova, pontuando desde já a fundamentação per relationem:

"Considerada a informação da serventia à fl. 392 no sentido de que a perícia técnica autorizada pelo juízo no aparelho de telefonia celular da acusada Neide não foi realizada até o momento, e levando-se em conta o desinteresse do Ministério Público na produção de tal prova, entendo não ser o caso de deferir a providência requerida pela Defesa em audiência. Explico. Pelo que consta das informações apresentadas pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante de Neide, durante a abordagem, ela teria recebido mensagem de aplicativo de um sujeito denominado "Edson", que coincidentemente tratava de assunto relacionado às drogas apreendidas. Portanto, em tese, segundo relato dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, o aparelho de telefonia celular conteria dados incriminadores, com informações relacionadas à prática do tráfico de drogas. Mas considerando a desistência expressa do Ministério Público na produção de perícia no equipamento de Neide, não há como se confirmar tal informação, e portanto, tal prova, que poderia ser prejudicial ao interesse da acusada, está completamente descartada. Por outro lado, não se vislumbra interesse da Defesa na realização de tal perícia, pois ainda que tal diligência viesse a confirmar a inexistência da suposta mensagem enviada pelo tal "Edson", ou ainda, caso confirmasse o efetivo envio, embora tratando de assunto absolutamente distinto, ou seja, uma mensagem aleatória ou casual, como as diversas mensagens recebidas diariamente por qualquer pessoa via "Whatsapp", tratar-se-ia de circunstância absolutamente irrelevante, sem qualquer interesse ao feito. Assim, na pior das hipóteses, a prova seria incriminadora, e na melhor das hipóteses, ao que tudo indica, seria irrelevante, a merecer indeferimento o pedido da Defesa, nos termos do artigo 440, § 1º, do CPP."

Apenas em complemento ao que já foi decidido, pelo que se deduz dos depoimentos colhidos, a referida conversa travada entre a acusada NEIDE e terceira pessoa supostamente denominada EDSON é incontroversa nos autos, pois segundo relato da policial Jessica, teria sido captada mensagem de áudio enviada por EDSON com o seguinte teor; "tem como você trazer as que já estão prontas pra mim?".

De outro lado, a acusada NEIDE, quando interrogada, confirmou a existência de referida mensagem, não impugnando sua existência, mencionando, no entanto, que em verdade, a cobrança realizada por Edson tinha por objeto máscaras de crochê, e não drogas.

Assim, pelo que se percebe, referida mensagem existiu, e ambos os lados confirmam, porém, não há certeza quanto ao seu real sentido, o que depende da interpretação promovida de acordo com o ponto de vista pessoal de cada um dos envolvidos. Se de um lado a policial afirma que a mensagem teria por objeto "drogas", a acusada rebate, asseverando que a conversa referia-se a "máscaras de crochê". Logo, ainda que fosse realizada a perícia no aparelho de telefonia celular, considerando que na breve mensagem supostamente enviada por EDSON via "whatsapp" não há explícita menção ao objeto que estaria "pronto", a conclusão continuaria a depender da versão pessoal dos envolvidos, e assim sendo, o resultado do trabalho técnico-policial seria inútil.

Quanto ao mérito, a materialidade do delito de tráfico restou comprovada pela prova colhida em contraditório, especificamente pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/16 e pelo laudo de exame toxicológico de fls. 103/105.

No tocante à autoria, algumas questões merecem ser apreciadas.

Ouvido em juízo, NELSON ALLE negou os fatos, relatando que conduzia seu veículo automotivo pelo centro da cidade, quando foi abordado pelos policiais, que nada encontraram em seu poder. Foi ao Banco do Brasil, realizou uma operação bancária, e no retorno, deparou-se com NEIDE, parando seu veículo para cumprimentá-la, sem realizar qualquer entrega à co-acusada.

NEIDE, por sua vez, ao ser interrogada, admitiu que detinha uma pedra de crack contendo 55,75g, negando, no entanto, que tenha recebido o entorpecente de NELSON. Sustentou que havia adquirido a droga apreendida em comunhão com outras pessoas para uso coletivo. Afirmou, ainda, que o restante da droga, consistentes em 49 pedras pequenas de crack, não foram encontradas em sua residência, mas sim numa garagem pertencente a uma residência próxima.

Os depoimentos testemunhais foram prestados pelos policiais que realizaram a abordagem de NEIDE, e que culminou na apreensão da droga e prisão em flagrante. As versões apresentadas em juízo basicamente confirmam os depoimentos da fase policial.

A prova produzida nos autos demonstra que os entorpecentes narrados na denúncia de fato foram encontrados, em maior parte, na posse de NEIDE, e o restante, escondidos em uma garagem, havendo controvérsia se pertencente ou não à residência de NEIDE.

As testemunhas não puderam certificar-se da prática de efetivo ato de mercancia por parte de NEIDE, no entanto, a conduta descrita na denúncia, "trazer consigo", bem como "ter em depósito, para fins de tráfico", compõe o tipo alternativo previsto pelo art. 33 da Lei de Drogas e veio devidamente amparada nos autos.

De fato, consideradas as circunstâncias concretas, é possível constatar que a quantidade de droga apreendida mostra-se incompatível com a alegação de uso por parte de NEIDE, ainda mais quando se verifica que a versão por ela apresentada, no sentido de que havia adquirido a droga com o propósito de compartilhar com terceiros, não se mostra verossímil, e tampouco ostenta mínima credibilidade.

A quantidade de droga apreendida é grande, ao menos no que diz respeito à verificação dos propósitos de aquisição para consumo próprio.

Entendo que a apreensão de quantidade expressiva de entorpecente é meio de prova do comércio e não mera presunção. É claro que, por si só, a quantidade não é suficiente para reconhecer o tráfico, mas, cotejada com outros elementos de prova e circunstâncias da apreensão, como ocorreu no caso, mostra-se meio hábil e legítimo para sustentar a ocorrência da mercancia.

A jurisprudência tem se alinhado à tese de que a quantidade do entorpecente, aliada a outros aspectos, é meio hábil para a caracterização do tráfico de entorpecentes:

"Levando-se em conta a grande quantidade de entorpecente encontrada, seu valor e o escasso poder de compra do acusado, aliando-se ao fato de que levava para o local de serviço, tem-se que está correta a classificação no artigo 12 da Lei nº 6.368/76" (TJSP, rel. Gentil Leite, RT 710/279).

"Tráfico - Apreensão de grande quantidade de maconha - Objetivo de comercialização indiscutível, ainda que se trate de réu dependente da erva entorpecente - Condição de traficante que se prepondera sobre a de viciado, posto que tinha ele o entendimento da ilicitude do tráfico" (TJSP - rel. MARINO FALCÃO, RJTJSP 84/382).

Ademais, a análise da prática do delito previsto no artigo 33 da Lei n. 11343/06 deve ser feita em conformidade com o contexto apresentado, de forma que o conjunto de elementos somados uns aos outros, por intermédio do raciocínio indutivo, faça "crescer o conhecimento do ser humano, unindo-se dados parciais para formar um quadro mais amplo" (NUCCI, CPP Comentado, p. 521, 9. Ed, RT).

De fato, a prova do crime no presente caso é valorada pelo conjunto de indícios, que de acordo com as ponderações do consagrado doutrinador GUILHERME DE SOUZA NUCCI "são perfeitos tanto para sustentar uma condenação quanto uma absolvição", ressaltando que "há autorização legal para a sua utilização e não se pode descuidar que há muito preconceito contra esse espécie de prova, embora seja imprescindível ao juiz utilizá-la" (Op. Cit., p. 514).

Além de trazer consigo uma pedra de crack com peso de mais de cinquenta e cinco gramas, o que, diga-se, permite a produção de centenas de pequenas pedras hábeis a serem comercializadas, ainda mantinha em depósito mais quarenta e nove pequenas pedras, já devidamente embaladas.

No que diz respeito ao endereço residencial da acusada NEIDE, destaque-se que realmente o imóvel indicado na fotografia de fl. 419 não detém efetivamente uma garagem, não se sabendo ao certo onde foram encontradas as quarenta e nove porções identificadas na fotografia de fl. 16, certamente em um imóvel bem próximo.

Mas ainda que as drogas não estivessem dentro dos limites do endereço residencial da acusada, deve-se considerar que ela levou os policiais até o local e lhes indicou onde estavam tais porções, até porque não é de se imaginar o encontro fortuito e repentino de drogas.

Outra hipótese, que se aventa no caso apenas para fins argumentativos, é a possibilidade dos policiais terem "forjado" as quarenta e nove porções, ou seja, terem obtido previamente a droga em outra ação e, de forma criminosa, terem imputado a posse à acusada. Mas tal possibilidade carece de sentido no caso em concreto, pois se a acusada detinha consigo uma quantia muito maior de entorpecente, correspondente a cinquenta e cinco gramas de crack em pedra bruta, não haveria qualquer razão lógica em se acrescentar criminosamente mais uma pequena parcela de drogas, que no caso, correspondente a 7,4 gramas, ou seja, um minus.

A ação de "forjar", analisando-se a questão apenas sob o prisma da lógica, evidentemente, somente teria plausibilidade em eventual tentativa de incriminar uma pessoa inocente, que não detivesse consigo qualquer droga, mas no caso, não se verifica resultado útil em se "incriminar" uma pessoa já "incriminada", e que detinha consigo uma parcela muito mais significativa da droga encontrada, que supera mais de sete vezes o que foi encontrado posteriormente.

Sob este prisma, não se ignora que o relato de agentes estatais, naturalmente interessados diretamente na avaliação positiva de suas condutas, deva ser

considerado com cautela pelo julgador. No entanto, a bem da verdade, todo e qualquer testemunho ou relato deve sempre ser analisado com cuidado pelo juiz, uma vez que é bastante provável que, por exemplo, a vítima tenha a tendência de "enxergar" os fatos de modo mais favorável a si, ou que as testemunhas procurem tornar suas declarações o mais convincentes possível.

Dessa forma, deve sempre o magistrado proferir sua decisão de acordo com o chamado livre convencimento motivado, fundamentando-a nos diversos elementos dos autos, admitindo-se a condenação quando estes se mostrem harmônicos, não se prescindindo da existência de prova colhida em contraditório judicial.

No caso em tela, portanto, não se demonstrando interesse pessoal dos agentes no objeto da investigação, tendo suas declarações sido confirmadas, em essência, pelos demais indícios dos autos, havendo coerência e verossimilhança nos relatos, evidente que se pode levá-los em conta para um decreto condenatório.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos".
(HC nº 74.608-0-SP - Rel. Min Celso de Mello).

Assim, resta incontroversa a realização da conduta descrita no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 pela acusada NEIDE TOSSIM.

De outro lado, não se demonstrou com a necessária certeza a participação do réu NELSON nos fatos.

Não se nega que NELSON é pessoa conhecida nos meios policiais, e já manteve relação íntima com a traficância local, mas a simples notícia informal de que "seria o chefe do tráfico na região" não se mostra suficiente para sua incriminação.

Ademais, constata-se fragilidade nas provas do envolvimento de NELSON, já que, embora realmente tenha sido registrado o contato mantido entre ele e NEIDE, não é possível ter certeza acerca do ato de entrega da pedra de crack encontrada com a acusada, até porque o acusado não foi interpelado imediatamente.

Ademais, NELSON havia sido abordado minutos antes pelos policiais, nada tendo sido encontrado em sua posse, e não é de se supor que ele viesse a se arriscar novamente, logo após ter sido revistado.

Assim, não se tendo certeza da ação conjunta e comunhão de interesses entre NELSON e NEIDE, prudente a absolvição do primeiro.

Passo a dosar a pena da ré NEIDE.

Observando as diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais, sendo que culpabilidade será considerada em cada uma das demais circunstâncias.

Nesse sentido, no que se refere motivos do crime, suas conseqüências, ao

comportamento da vítima, à conduta social e à personalidade do agente, tem-se que não há qualquer elemento que torne a conduta da ré mais fortemente reprovável além do que já previsto no tipo penal em abstrato.

Quanto aos antecedentes da ré, que são os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, tem-se que este ostenta algumas passagens muito remotas, não se mostrando razoável nem pertinente utilizar tais fatores como elementos de exasperação da pena.

No que se refere às circunstâncias do crime, que são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução, tem-se que no presente delito, levando-se em conta o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, no sentido de que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente", é de se reconhecer que a não muito alta quantidade de droga – mas suficiente para se ter, diante das circunstâncias do caso, como incompatível para o uso –, não enseja a elevação da pena-base.

Desse modo, considerando-se os elementos analisados acima, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, até porque a acusada apenas confessou parcialmente os fatos, admitindo a posse de parte das drogas apenas para fins de uso.

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, visto que estão presentes os requisitos legais, pois a ré é tecnicamente primária, não ostenta maus antecedentes e não há provas nos autos de sua dedicação a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa.

Discorrendo sobre os critérios para referida diminuição da pena, leciona Guilherme de Souza Nucci que "o legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir a pena de um sexto a dois terços. cremos que, como sempre, deve o julgador pautar-se pelos elementos do art. 59 do Código Penal, com a especial atenção lançada pelo art. 42 desta Lei' (...) É lógico que há de existir o cuidado de evitar o bis in idem, ou seja, levarem conta duas vezes a mesma circunstância. Como temos defendido em outros trabalhos, as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual. Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário, de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como a pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério diminuição da pena (ex : dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base (a primeira etapa da aplicação da pena, conforme art. 68 do Código Penal). O contrário também se dá. Percebendo enorme quantidade de drogas, ainda que em poder de traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações com o crime organizado, pode reservar tal circunstância para utilização na diminuição da pena (ex.. um sexto). Se assim o fizer, não se valerá da mesma circunstância por ocasião da eleição da pena-base, com fundamento no art. 59 do CP" (Leis penas e Processuais Penais Comentadas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 332/333).

Portanto, considerando a quantidade da substância entorpecente apreendida em poder da acusada, compatível com o que se pode considerar "tráfico de pequeno porte", aplico o patamar máximo de 2/3 (metade) para a diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11/343/2006, fixando-a definitivamente em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (art. 33, 2.º, "c" e §3º., do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque a ré é primária, não ostenta antecedentes criminais, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis e foi afastado pela jurisprudência do STF e do STJ o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, CONDENANDO o acusado NEIDE TOSSIM, a uma pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, como incursa no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, ABSOLVO o réu NELSON ALLE SIMÕES de referida imputação, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Considerando a redação do art. 44, §2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano, a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal). A substituição é cabível, pois a acusado não é reincidente em virtude da prática do mesmo crime (art. 44, §3.º, do Código Penal) e a medida é recomendável, uma vez que o presente crime não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

Ademais, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade por outro crime o juiz da execução decidirá sobre a conversão (art. 44, §5.º, do Código Penal).

Os réus poderão recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, decreto a perda do bem apreendido com NEIDE em favor da União Federal.

Expeça-se o necessário.

Custas conforme a lei.

P.I.C.

Limeira, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA